

1501579-46.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290224/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21003315 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6496/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501579-46.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290224/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21003315 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6496/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2290224 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6496/21/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SILVA MARQUES COSTA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 05 de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de

procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) THIAGO SILVA MARQUES COSTA, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns VITOR FERREIRA BRITO DOS SANTOS e EDUARDO SOARES; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, os depoimentos, interrogatórios, e/ou alegações finais foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams", e nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estarão disponíveis o E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) EDUARDO e VITOR, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): THIAGO SILVA MARQUES COSTA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Três Lagoas, 3701, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 01 porção de maconha (tetrahydrocannabinol), pesando 242,91 gramas, 20 pedras de crack (cocaína na forma de pedras de crack), pesando 5,74 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 12, laudo de constatação prévia às fls. 26/29 e exame químico-toxicológico definitivo às fls.), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Conforme apurado, na data dos fatos, policiais, em patrulhamento de rotina nas imediações do local dos fatos, local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado Tiago em pé, em via pública, entregando alguma coisa para o motorista de um veículo corsa wind, de cor vermelha, o que chamou a atenção. O acusado, ao perceber que iria ser abordado, empreendeu em fuga e pulou o muro de uma residência, subindo no telhado, e assim continuou em fuga, pulando de casa em casa. Os policiais passaram a acompanhá-lo e solicitaram apoio pelo rádio. Thiago foi abordado em uma casa das imediações, de numeral 3741. Em revista pessoal, no bolso de sua blusa, foram localizadas drogas, tipo crack, embaladas em pequenas porções, e no bolso da bermuda R\$ 21,00. Thiago confessou que fazia a venda de entorpecentes pelo local e que também possuía mais drogas escondidas em uma casa, de numeral 3701, mais especificamente, na varanda, em uma calha externa, local em que foi encontrado um tijolo de maconha, embalado em plástico filme transparente. Pela considerável quantidade de droga apreendida, local da abordagem e comportamento do denunciado na ocasião de sua prisão, demonstra-se inequivocamente que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização e entrega a terceiros. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão das drogas – maconha e crack – consoante auto de exibição e apreensão de fls. 12, pelo laudo de constatação de fls. 27 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 75/78, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol THC e cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SVS/MS, e atualizações posteriores. A autoria atribuída ao réu na denúncia também restou comprovada. Interrogado em juízo, o réu confessou a posse e propriedade das drogas apreendidas. Disse que estava desempregado e pegou as drogas para vender nos finais de semana. A maconha era para seu consumo e o crack era para venda. A confissão

judicial do réu restou corroborada pela prova testemunhal produzida.

O policial militar Vitor Ferreira Brito dos Santos, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 5) e depois em juízo, declarou que na data dos fatos estava em companhia de seu colega de farda Eduardo Soares em patrulhamento de rotina no Bairro Solo Sagrado quando no local indicado na denúncia (Rua Três Lagoas, 3701), conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado na via pública entregando algo ao motorista de um veículo Corsa Wind, atitude típica de venda e entrega de droga, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ao perceber que seria abordado o acusado empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência, subindo no telhado, e assim continuou em fuga, pulando de casa em casa. Em razão disso começou a perseguir o acusado também pulando os telhados das casas, e de imediato solicitaram apoio pelo rádio, e após a chegada de mais viaturas, o acusado foi localizado em uma casa das imediações de numeral 3741. O acusado percebeu que estava cercado por policiais e rendeu-se. Em revista pessoal, localizaram no bolso da blusa do acusado pedras de crack embaladas em pequenas porções, e no bolso da bermuda R\$ 21,00 em dinheiro. O acusado confessou que fazia a venda de entorpecentes no local e que também havia mais drogas escondidas em uma casa, de numeral 3701, mais especificamente, na varanda, em uma calha externa. Na referida casa, no local indicado pelo próprio acusado, encontraram parte de um tijolo de maconha, embalada em plástico filme transparente. No momento da detenção a sacola contendo as pedras de crack estavam no bolso. O policial militar Eduardo Soares, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 3) e depois em juízo, confirmou o depoimento judicial de seu colega de farda Vitor Ferreira Brito dos Santos. Declarou que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina no Bairro Solo Sagrado quando no local indicado na denúncia (Rua Três Lagoas, 3701), conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado na via pública, com uma sacola na mão, entregando algo ao motorista de um veículo Corsa Wind, atitude típica de venda e entrega de droga, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ao perceber que seria abordado o acusado empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência, subindo no telhado, e assim continuou em fuga, pulando de casa em casa. Em razão disso começou a perseguir o acusado também pulando os telhados das casas, e de imediato solicitaram apoio pelo rádio, e após a chegada de mais viaturas, o acusado foi localizado em uma casa das imediações de numeral 3741. O acusado percebeu que estava cercado por policiais e rendeu-se. Em revista pessoal, localizaram no bolso da blusa do acusado pedras de crack embaladas em pequenas porções, e no bolso da bermuda R\$ 21,00 em dinheiro. O acusado confessou que fazia a venda de entorpecentes no local e que também havia mais drogas escondidas em uma casa, de numeral 3701, mais especificamente, na varanda, em uma calha externa. Na referida casa, no local indicado pelo próprio acusado, encontraram parte de um tijolo de maconha, embalada em plástico filme transparente. No momento da detenção do acusado a sacola contendo as pedras de crack estavam no bolso. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito atribuída ao réu na denúncia, a condenação se impõe. O réu possui três (3) condenações definitivas: a) 0000187-87.2017.8.26.0559 - 5ª Vara Criminal de Rio Preto - tráfico ilícito de drogas - trânsito em julgado para a defesa em 18/9/2017; b) processo nº 000743-26.2016.8.26.0559 - 4ª Vara Criminal - furto - trânsito em julgado para a defesa em 2/5/2018; e, c) 020131-58.2016.8.26.0576 - 1ª Vara Criminal - furto - trânsito em julgado para a defesa em 3/7/2018. Portanto, além de reincidente específico, ostenta maus antecedentes. A pena base deve ser fixada acima do mínimo legal levando-se em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a personalidade do réu voltada para a prática reiterada de crimes e os maus antecedentes - a condenação por tráfico ilícito de drogas deve ser considerada para o reconhecimento da reincidência específica e as outras duas condenações por furtos como maus antecedentes -. A reincidência específica do acusado deve ser reconhecida como agravante genérica, mas compensada com a atenuante da confissão espontânea. Em razão da reincidência deve ser afastada da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33

da Lei nº 11.343/2006, e fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu THIAGO SILVA MARQUES COSTA como incurso nas sanções

do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 Requer, ainda, a decretação do perdimento definitivo do dinheiro apreendido, produto do narcotráfico, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (Banco do Brasil, ag. 3602-1, conta 170.500-8, código identificador do depósito para o Estado de São Paulo: 110.001-20904-102-6 numerários, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas). Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença:

"Vistos. THIAGO SILVA MARQUES COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Três Lagoas, 3701, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 01 porção de maconha, pesando 242,910 gramas, 20 pedras de crack, pesando 5,740 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra a denúncia que policiais, em patrulhamento de rotina nas imediações do local dos fatos, local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado na via pública, entregando alguma coisa para o motorista de um GM/Corsa de cor vermelha, o que chamou a atenção, mas percebendo que seria abordado, o acusado empreendeu em fuga e pulou o muro de uma residência, subindo no telhado, e assim continuou em fuga, pulando de casa em casa. Os policiais passaram a acompanhá-lo e solicitaram apoio pelo rádio, sendo o acusado abordado em uma casa das imediações, sendo que em revista pessoal, no bolso de sua blusa, foram localizadas drogas, tipo crack, embaladas em pequenas porções, e no bolso da bermuda a quantia de R\$21,00. Narra que o acusado confessou que fazia a venda de entorpecentes pelo local e também que possuía mais drogas escondidas em uma casa, de numeral 3701, mais especificamente, na varanda, em uma calha externa, local onde foi encontrado um tijolo de maconha embalado em plástico filme transparente. Notificado (fl. 81), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 85). Recebida a denúncia (fls. 88/90), o réu foi citado. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa sustentou a absolvição, alegando falta de provas. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado negou a prática do narcotráfico, assumindo a propriedade apenas da porção de maconha, cerca de 200 gramas, pela qual pagou a quantia de R\$300,00 e se destinava ao consumo próprio. Negou a propriedade do crack. Afirmou que a droga estava na casa de sua avó, onde os policiais fizeram buscas sem autorização. Em Juízo o réu confessou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que realmente trazia consigo o crack para venda. Estava desempregado, razão pela qual resolveu vender drogas e isso há cerca de um mês. Também guardava a maconha e esta também usava para o próprio consumo. Os policiais Eduardo Soares e Vitor Ferreira Brito dos Santos, no auto de prisão em flagrante, afirmaram que durante patrulhamento pelo local, conhecido ponto de narcotráfico, avistaram o acusado entregando algo para o condutor de um veículo, e ao notar que seria abordado, o acusado empreendeu fuga, pulando o muro de uma residência e subindo no telhado, continuando a escalar outras casas. Solicitaram apoio e o acusado acabou sendo abordado em uma casa nas imediações, de numeral 3741. Em poder do acusado, no bolso de sua blusa, apreenderam crack embalado em pequenas porções, e no bolso da bermuda a quantia de R\$ 21,00. O acusado confessou que fazia a venda de entorpecentes pelo local e que também havia mais drogas escondidas em uma casa, de numeral 3701, mais especificamente, na varanda, em uma calha externa. No local indicado pelo acusado apreenderam uma parte de um tijolo de maconha, embalada em plástico filme transparente. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação. A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.1/12 (auto de prisão), fls.76/77

(laudo) e pela prova oral. De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado, mormente porque a prova dos autos demonstra que o entorpecente apreendido pertencia ao acusado, se destinava ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem. Ademais, os policiais foram taxativos em afirmar que o local é conhecido ponto de narcotráfico e o acusado empreendeu fuga logo que notou a aproximação da viatura. Feita a abordagem com o acusado apreenderam dinheiro e porções de crack, e depois, no local indicado pelo próprio acusado, localizaram grande porção de maconha. Ademais, os policiais foram incisivos em afirmar que o acusado confessou a prática do narcotráfico, assumindo a propriedade das drogas apreendidas. Ressalte-se ainda a confissão judicial do réu, merecendo destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288). No mesmo caminho segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi - Data de registro 23/04/2010). Vale ressaltar ainda a importância de se aferir o modo de vida do acusado, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas. Ademais, não restou comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido. Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa ao réu, que sequer conheciam. Aliás, como já se decidiu, "Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial" (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180). No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304). "Art. 33, caput, da

Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos – Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido” (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018). Por fim, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato do réu portar e armazenar os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do piso, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero a natureza de parte da droga apreendida, crack, extremamente nociva, que devasta famílias e contribui sobremaneira com o aumento da criminalidade, dificultando o convívio social. Levo em consideração ainda a diversidade de drogas, sendo apreendida ainda cerca de 240 gramas de maconha. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 103, 103/104 e 105/106) e uma condenação compenso com a atenuante da confissão espontânea e as outras utilizo para majorar a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo a unidade. Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: “Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado ostenta outras condenações, sendo reincidente, logo, fica afastada a aplicação do redutor. Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente. 4. Conforme

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. (...) 7. Habeas corpus não conhecido" (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu). Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de ostentar outras condenações, sendo reincidente, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, inclusive crack, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeu e a pena a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão. Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285). O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançou o tempo que lhe permitiria a progressão de regime. Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu THIAGO SILVA MARQUES COSTA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo a unidade. Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal. Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 89). Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do numerário apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita do bem apreendido. Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Em seguida, o(a) acusado(a) manifestou interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a) foi dito que recebia o recurso. Abra-se vista à Defensoria Pública, para o oferecimento das razões de recurso, no prazo legal. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente